

KHAIRUNNISAK BINTI KHALID @ ABDUL TALIB
lwn.
MOHAMMAD ZULKARNAIN BIN MOHAMAD ZULKIFLI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-074-0150-2017

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Puan Norhasliza Binti Dzulkepeli daripada Tetuan Norhasliza Dzulkepeli & Associates

Peguam Syarie Responden: Puan Siti Maisyarah Binti Hashim daripada Tetuan Maisyarah & Mashitah & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 6 Disember 2017 dalam kes saman no. 10200-074-0159-2016. Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah meluluskan permohonan pengkomitan Pemohon berdasarkan Seksyen 151 (1) (b) (aa;
- 1.2 Mahkamah mensabitkan Responden melanggar Perenggan 2, 3 dan 4 Perintah Mahkamah; dan Responden dikomitkan ke penjara tiga (3) hari mulai hari ini.
- 2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 6 Disember 2017 dan mengemukakan tujuh (7) alasan rayuan bertarikh 19 Mac 2018 seperti di muka surat 152-153 Rekod Rayuan.
- 3) Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon rayuan ini ditolak dengan kos sebanyak RM15,000 .

FAKTA KES

- 4) Perayu dan Responden telah bercerai pada 16 Julai 2012. Sepanjang tempoh perkahwinan pasangan ini telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata iaitu Muhammad Rayyan Mikhail Bin Mohammad Zulkarnain No My Kid: 110303-02-0373.

5) Pada 7 November 2012, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah hadhanah berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak dengan memerintahkan seperti berikut;

- 5.1 *Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak diberikan kepada pihak Plaintiff (ibu) ke atas anak yang bernama Muhammad Rayyan Mikhail Bin Mohammad Zulkarnain No My Kid: 110303-02-0373.*
- 5.2 *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama dengan anak tersebut hendaklah diberikan kepada pihak Defendan (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dan dimaklumkan kepada Plaintiff sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum perjumpaan.*
- 5.3 *Mahkamah memerintahkan hak bermalam diberikan kepada pihak Defendan sebanyak dua (2) kali hujung minggu dalam sebulan dan dimaklumkan kepada pihak Plaintiff satu (1) hari sebelum pengambilan.*
- 5.4 *Mahkamah memerintahkan cara pelaksanaan hak bersama dan bermalam;*
 - 5.4.1 *Defendan hendaklah memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff akan kehadirannya untuk bersama atau bermalam dengan anak tersebut. Makluman tersebut hendaklah dimaklumkan sekurang-kurangnya sehari sebelum pengambilan atau perjumpaan.*

- 5.4.2 *Defendan dibenarkan untuk mengambil anak untuk bermalam mulai hari Jumaat jam 6.00 petang dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad sebelum atau pada jam 6.00 petang.*
- 5.4.3 *Defendan dibenarkan berjumpa atau mengambil anak tersebut di tempat Plaintiff dan anak tersebut tinggal (bermastautin) atau di mana-mana tempat yang dipersetujui oleh pihak-pihak secara bersama.*
- 5.4.4 *Sebelum anak tersebut mencapai umur lima (5) tahun (sebelum Prasekolah) anak tersebut akan bermalam bersama Defendan selama satu minggu pada bulan Disember bagi setiap tahun. Defendan hendaklah memaklumkan kepada pihak Plaintiff selewat-lewatnya satu minggu sebelum pengambilan.*
- 5.5 *Mahkamah memerintahkan bagi cuti penggal persekolahan, anak tersebut akan bermalam bersama pihak-pihak secara sama-rata. Jika anak tersebut mempunyai kegiatan kokurikulum atau kelas tambahan pada cuti persekolahan, pihak yang bersama anak tersebut hendaklah menghantar anak tersebut ke tempat yang dimaklumkan.*
- 5.6 *Mahkamah memerintahkan bagi sambutan Hari Raya Puasa 1435H, anak tersebut hendaklah bersama dengan pihak Defendan selama 4 hari (sehari sebelum hari raya sehingga*

tengah hari hari raya ketiga). Bagi pihak yang tidak dapat menyambut Hari Raya Puasa yang pertama dengan anak tersebut akan menyambut Hari Raya Haji dengan anak pada tahun tersebut. Pihak-pihak mestilah membuat penggiliran secara adil bagi setiap tahun agar masing-masing dapat menyambut perayaan bersama anak tersebut dengan suasana yang harmoni.

- 5.7 Mahkamah memerintahkan pihak Defendan diberi hak berhubung dengan anak tersebut melalui apa jua alat telekomunikasi atau media elektronik pada bila-bila masa yang munasabah tanpa menjejaskan jadual persekolahan anak tersebut.
- 5.8 Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak yang menjaga anak tersebut ketika waktu penjagaan adalah bertanggungjawab ke atas kebajikan anak yang di bawah jagaannya ketika itu. Jika berlaku apa-apa kecemasan, pihak-pihak yang bersama anak tersebut hendaklah memaklumkan kepada pihak yang satu lagi.
- 5.9 Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak yang bersama anak tersebut ketika waktu penjagaan hendaklah mendidik anak tersebut secara ajaran Islam (ahli summah wal jamaah) dan menjaga akhlak islamiah serta menunjukkan tingkah laku yang baik ketika bersama anak tersebut. Ini adalah

untuk menjaga penghormatan dan tatasusila anak terhadap pihak-pihak.

- 5.10 Mahkamah memerintahkan bagi hal-hal kecemasan dan keraian, pihak-pihak yang hendaklah bersama anak tersebut pada hal-hal yang disebutkan di atas, hendaklah memaklumkan terlebih dahulu kepada pihak yang satu lagi. Pihak yang hendaklah bersama anak tersebut juga hendaklah memaklumkan tempoh masa yang diperlukan untuk bersama anak tersebut.*
- 5.11 Mahkamah memerintahkan segala urusan dan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan agama, pendidikan, kesihatan dan keselamatan anak tersebut hendaklah dibuat secara bersama, pihak-pihak hendaklah bersama-sama berbincang dan mencapai persetujuan secara bersama.*
- 5.12 Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak adalah dilarang daripada membuat kacau ganggu terhadap pihak yang satu lagi dan menghasut anak tersebut membeci pihak yang satu lagi demi menjaga kehormatan pihak-pihak.*
- 5.13 Mahkamah memerintahkan pihak Plaintif dan Defendan hendaklah bersikap kodial, saling bekerjasama dan bertolak ansur berkenaan hak bersama anak tersebut dengan*

meletakkan kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut sebagai paling afdhal dan terutama.

5.14 *Mahkamah memerintahkan jika sekiranya berlaku sebarang perubahan matan sama ada Plaintiff atau Defendan telah berkahwin lain, perpindahan tempat pekerjaan, tempat tinggal, perubahan ekonomi, pertukaran nombor telefon, menghidapi penyakit yang merbahaya serta tidak berkeupayaan maka Plaintiff dan Defendan hendaklah saling memaklumkan antara satu sama lain dalam masa 14 hari daripada tarikh perubahan berlaku serta menyelesaikan masalah melalui perbincangan agar kebajikan anak tersebut tidak terjejas.*

6) Pada 9 Mac 2016, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab kerana;

6.1 Perayu sengaja telah ingkar perintah Mahkamah bertarikh 29 November 2013 di perenggan 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14.

6.2 Perayu dengan sengaja dan berniat untuk melakukan pelanggaran dan keingkaran terhadap perintah tersebut apabila segala perhubungan komunikasi antara Perayu dan Responden disekat. Malah Perayu dengan sengaja enggan

memberi respon terhadap perhubungan komunikasi Responden sama ada melalui panggilan telefon ataupun pesanan ringkas. Malahan Perayu juga turut tidak memberi kerjasama apabila Responden datang ke rumah Perayu untuk berjumpa anak. Perayu juga telah sengaja berpindah ke kampung Perayu tanpa memaklumkan kepada Responden menyebabkan sehingga hari ini Responden tidak tahu di mana anak tersebut berada dan keadaan anak tersebut.

- 6.3 Perayu telah dengan sengaja mengingkari perintah yang telah dibuat secara persetujuan bersama tersebut tanpa alasan yang munasabah menyebabkan hak Pemohon sebagai seorang bapa telah dinafikan sepenuhnya. Sehingga kes difailkan Responden telah gagal berjumpa dengan anak tersebut selama lebih kurang dua tahun sejak dari bulan Disember 2012.

7) Pada 25 Julai 2016, Mahkamah telah membenarkan permohonan Responden untuk mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab terhadap Perayu untuk menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana telah ingkar dan tidak mematuhi perintah Mahkamah di perenggan 2, 3 dan 4 perintah bertarikh 7 November 2013 melalui saman no. 10300-028-0687-2012 .

8) Perayu telah memfailkan affidavit jawapan pada 10 April 2017. Kemudiannya kes diteruskan untuk keterangan Perayu dan Responden telah memfailkan hujah bertulisnya pada 27 November 2017 manakala Perayu telah memfailkan hujah bertulis pada 26 Oktober 2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Kami akan rangkumkan kesemua alasan rayuan kepada satu isu iaitu sama ada YA Hakim Perbicaraan telah terkhilaf apabila mensabitkan bahawa Perayu telah melanggar Perenggan 2, 3 dan 4 Perintah Persetujuan bertarikh 7 November 2013 melalui saman no. 10300-028-0687-2012.

10) **Merujuk kepada Rekod Rayuan muka surat 157**, kami dapati satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan oleh Mahkamah terhadap Perayu bertarikh 25 Julai 2016 untuk menunjuk sebab mengapa Perayu tidak patut dikomitkan ke penjara kerana telah ingkar dan tidak mematuhi perintah Mahkamah di perenggan 2, 3 dan 4. Terma perintah berkaitan perenggan 2, 3 dan 4 tersebut adalah sepertimana yang dinyatakan di perenggan 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 dan 5.4.4 di atas.

11) Kami dapati terma perintah di perenggan 2, 3 dan 4 tersebut adalah bersifat umum kerana tidak menyatakan secara khusus masa lawatan dan

masa bersama serta minggu-minggu yang dibenarkan untuk anak tersebut bermalam bersama Responden. Pelaksanaan bagi terma dalam perintah tersebut adalah tertakhluk kepada pemakluman oleh Responden kepada Perayu sehari sebelum masa lawatan dan bermalam dijalankan. Untuk mensabitkan Perayu melanggar terma di perenggan 2, 3 dan 4 perintah tersebut, kami berpendapat terdapat dua elemen yang perlu diperhalusi oleh Mahkamah iaitu;

11.1 Tarikh dan masa hak lawatan, bersama dan bermalam yang telah dilanggar oleh Perayu; dan

11.2 Sama ada pemakluman telah dibuat oleh Responden sebelum hak lawatan, bersama dan bermalam dilaksanakan.

Elemen-elemen ini adalah sangat penting untuk memastikan bahawa dakwaan tersebut memenuhi kehendak undang-undang dan hukum syarak.

12) Kami telah meneliti ulasan YA Hakim Perbicaraan di **muka surat 122-149 Rekod Rayuan** dan kami dapati tidak ada ulasan fakta berkaitan tarikh dan masa pelanggaran dilakukan serta sama ada Responden telah membuat pemakluman kepada Perayu atau tidak sebelum melawat atau mengambil anak tersebut untuk tujuan bermalam. Fakta berkaitan tarikh dan masa pelanggaran juga tidak dinyatakan dalam notis tunjuk sebab yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah. Oleh yang demikian kami berpendapat dakwaan Responden

dan Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan oleh Mahkamah adalah bersifat fasidah. Ulasan berkaitan dakwaan fasidah ini boleh dirujuk dalam kes (**Anuar bin Nordin lwn. Rozana binti Ramli kes rayuan no. 14000-041-0039-2018 dan kes zolkepley bin Abdol Majid lwn. Animah binti Ahim, kes rayuan no. 06000-017-0008-2015**).

13) Keperluan menyatakan fakta tentang sesuatu dakwaan telah diperuntukkan berdasarkan Seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor);

“(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.”

14) Kami juga bersetuju dengan ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes yang dirujuk oleh Perayu iaitu kes

(Baidura binti Bahari lwn. Ahmad Haidzir bin Anuwar dan Hamidah binti Bakar, kes rayuan no. 10000-036-0058-2015).

“ Kami hanya menemui fakta berkenaan perenggan (g) yang telah diulas Hakim Bicara di dalam Afidavit Tambahan Responden 1 (Amad Haidzir Bin Anuwar) bertarikh 29/3/2013 (m.s 68-73 Rekod Rayuan) sahaja. Selain daripada itu, tidak terdapat apa-apa fakta berkenaan perlanggaran perenggan (g) di mana-mana kertas pliding Responden, di dalam Notis Tunjuk Sebab (m.s 103-105 Rekod Rayuan), di dalam Nota Keterangan (ketika prosiding soal utama, soal balas dan soal semula) (m.s 121-131 Rekod Rayuan) dan di dalam penghujahan bertulis Responden (m.s 133-149 Rekod Rayuan). Sedangkan apa yang menjadi kewajipan kepada Perayu hanyalah untuk menjawab apa-apa fakta di atas pengetahuannya yang telah dinyatakan di dalam Notis Tunjuk Sebab sahaja.

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan ulasan Hakim Bicara ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaan perlanggaran perenggan (g) Perintah

Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaan fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran pereanggan (g) adalah diluar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara. “

15) Dalam rayuan ini kami dapati YA Hakim Perbicaraan telah mensabitkan Perayu melanggar terma perenggan 2, 3 dan 4 perintah semata-mata berdasarkan pengakuan Responden seperti mana ulasan YA Hakim Perbicaraan di **perenggan 39, muka surat 145 Rekod Rayuan.**

“Justeru itu, berdasarkan pengakuan Responden ini tentang kegagalan memaklumkan kepada Pemohon tentang perpindahan tempat tinggal serta pertukaran nurseri anak tersebut sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat berjumpa, bersama dan bermalam dengan anak tersebut ternyata melanggar perintah di perenggan 2, 3 dan 4 perintah hadhanah yang mana telah dipersetujui secara bersama pada 7 November 2013. Maka Mahkamah mensabitkan bahawa Responden telah sengaja melanggar perintah di perenggan 2, 3 dan 4 perintah hadhanah pada 7 November 2013. “

16) Kami dapati pengakuan Perayu berhubung kegagalan memaklumkan kepada Pemohon tentang perpindahan tempat tinggal serta pertukaran nurseri anak tersebut adalah isu yang berbeza dengan pelanggaran perenggan 2, 3 dan 4 perintah. Pada hemat kami pengakuan tersebut adalah lebih sesuai disabitkan dengan pelanggaran kepada perenggan 14 perintah seperti mana petikan perintah yang dinyatakan pada perkara 5.14 di atas.

“Mahkamah memerintahkan jika sekiranya berlaku sebarang perubahan matan sama ada Plaintiff atau Defendan telah berkahwin lain, perpindahan tempat pekerjaan, tempat tinggal, perubahan ekonomi, pertukaran nombor telefon, menghadapi penyakit yang merbahaya serta tidak berkeupayaan maka Plaintiff dan Defendan hendaklah saling memaklumkan antara satu sama lain dalam masa 14 hari daripada tarikh perubahan berlaku serta menyelesaikan masalah melalui perbincangan agar kebajikan anak tersebut tidak terjejas.”

17) Seterusnya, timbul persoalan di peringkat kami sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh mensabitkan Perayu telah melanggar terma perenggan 14 perintah sedangkan pelanggaran terma tersebut tidak dinyatakan dalam Notis Tunjuk Sebab. Secara ringkasnya pandangan kami berkaitan persoalan ini adalah sama seperti ulasan kami di perenggan 14 di atas. Ketidadaan perenggan 14 perintah dalam Notis Tunjuk Sebab telah menyebabkan hak Perayu dinafikan untuk menjawab dan menunjuk sebab menapa alasan perlanggaran itu berlaku. Kami juga

mendapati terdapat dakwaan yang sama telah dilakukan oleh Responden yang telah berpindah dan bertukar tempat kerja serta berkahwin lain tanpa pemakluman kepada Perayu. Perkara ini tidak diperhalusi oleh YA Hakim Perbicaraan disebabkan perkara ini tidak dijadikan sebagai asas dalam tindakan pengkomitan . Ini menunjukkan bahawa terdapat kekhilafan YA Hakim Perbicaraan di peringkat awal penilaian terhadap permohonan kebenaran pengeluaran Notis Tunjuk Sebab yang akhirnya mengakibatkan berlaku kesilapan dalam mengklasifikasikan terma perintah yang dilanggar. Dalam rayuan ini kami juga mendapati tidak ada rayuan balas dikemukakan oleh Responden untuk mewajarkan kami campur tangan terhadap isu perenggan 14 perintah.

KEPUTUSAN

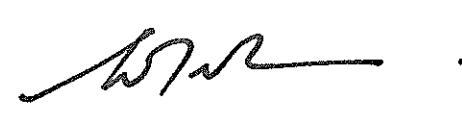
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes saman no. 10200-074-0159-2016 bertarikh 6 Disember 2017 adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor